

RECURSO CÍVEL Nº 5063209-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DURVAL DE SOUZA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARÁTER INDENIZATÓRIO, MAS DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE DETERMINADA FUNÇÃO EM DETERMINADA LOCALIDADE. ISENÇÃO DO TRIBUTO EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/2004. ENTENDIMENTO DA TNU. TEMA 235. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos da fundamentação supra. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se as partes e transitado em julgado, certifique-se, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

5063209-43.2024.4.02.5101

510014434435 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063209-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DURVAL DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso da parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, de condenar a ré a se abster de cobrar contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de GACEN e a ressarcir os valores cobrados, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, a União alega que os artigos 92 a 94 da Lei nº 13.324/2016, com a redação dada pela Lei nº 13.464/2017, permitiram a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, tanto a servidores ativos como a aposentados. Aduz que *se a parte Autora optou por incorporar integralmente a GACEN a seus proventos, representaria a concessão de verdadeiro privilégio deferir-se o afastamento da incidência da contribuição previdenciária.*

Contrarrazões apresentadas pela parte autora postulando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

O autor é servidor público federal, exercendo a função de guarda de endemias. Alega que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o GACEN, pois que essa gratificação se enquadraria no conceito de “parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho” de que trata o inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.887/04.

A GACEN foi criada pela Medida Provisória nº 431/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.784/2008, em substituição à indenização de campo anteriormente percebida pelos guardas de endemias, como se extrai dos dispositivos dessa lei:

Art. 54. Fica instituída, a partir de 1o de março de 2008, a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 55. A Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas.

§ 1o Revogado

§ 2o A Gacen será devida também nos afastamentos considerados de efetivo exercício, quando percebida por período igual ou superior a 12 (doze) meses.

§ 3o Para fins de incorporação da Gacen aos proventos de aposentadoria ou às pensões dos servidores que a ela fazem jus, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012)

I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen será:

a) a partir de 1o de março de 2008, correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu valor; e

b) a partir de 1o de janeiro de 2009, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do seu valor; e

II - para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando aos servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes do inciso I deste parágrafo; e

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.

§ 4o A Gecen e a Gacen não servirão de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou vantagens.

§ 5o A Gecen e a Gacen serão reajustadas na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.

§ 6o A Gecen e a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança.

§ 7o A Gecen e a Gacen substituem para todos os efeitos a vantagem de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991.

§ 8o Os servidores ou empregados que receberem a Gecen ou Gacen não receberão diárias que tenham como fundamento deslocamento nos termos do caput deste artigo, desde que não exija pernoite.

Art. 55-B. A partir de 1o de janeiro de 2013, os valores da GECEN e da GACEN são os constantes do Anexo XLIX-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.778, de 2012)

Art. 56. A partir de 1o de fevereiro de 2009, a estrutura salarial dos empregos públicos de Agente de Combate às Endemias, no âmbito do Quadro Suplementar de Combate às Endemias, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, passa a ser a constante do Anexo XLVIII, observada a correlação estabelecida na forma do Anexo XLIX desta Lei.

Art. 57. O Anexo da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo L desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.

Inicialmente, o fato de a gratificação em comento substituir a indenização de campo, nos termos do artigo 55, §7º da Lei nº 11.784/2008, não é suficiente para caracterizá-la como de caráter indenizatório.

Isso porque, como se extrai do parágrafo 3º do artigo 55 do texto legal, a GACEN se incorpora aos proventos de aposentadoria e pensão, sendo certo que o artigo 49 da Lei nº 8.112/1990 assim expõe:

Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

No entanto, como se extrai da norma supratranscrita (artigo 55, *caput*, da Lei nº 11.784/2008) a GACEN é devida em razão do exercício de determinada função ("aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias") em determinada localidade ("em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas").

A Lei nº 10.887/2004, por sua vez, prescreve em seu artigo 4º, §1º, VII, isenção do tributo em questão para as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, como se pode constatar:

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição.

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte;

IV - o salário-família;

V - o auxílio-alimentação;

VI - o auxílio-creche;

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VIII- a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e

IX- o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Deste modo, incabível a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação, vez que a mesma é devida tanto em virtude da atividade desempenhada quanto em razão do local em que realizada a atividade.

Neste mesmo sentido se manifestou a TNU na sessão de 06 de agosto de 2014 por ocasião do julgamento do processo nº 0006275-98.2012.4.01.3000:

"ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). INCIDÊNCIA SOBRE IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008. ADICIONAL DEVIDO EM RAZÃO DO LOCAL DO TRABALHO, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA (ART. 55, CAPUT). NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA PARA OS FINS DE APURAR A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE

SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/2004 QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO "AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE LOCAL DE TRABALHO". PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO."

Ainda, a TNU se manifestou também na sessão de 03/03/2021 por ocasião do julgamento do PEDILEF 5006060-68.2018.4.04.7001/PR, Tema 235, tese firmada que destaco:

"A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemia - GACEN tem caráter geral, uma vez que é paga de forma genérica, ou seja, independentemente de avaliação de produtividade, aos ocupantes dos cargos mencionados no art. 53 e no art. 54 da Lei n. 11.784/2008, que comprovem o exercício de atividade de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas".

Desta forma, sendo reconhecido o enquadramento da GACEN com as manifestações da TNU acima, por ocorrer em razão do local em que o trabalhador desempenha a atividade, é indevida a incidência de PSS sobre esta.

Sendo assim, reconhecido o recebimento da GACEN em razão do local em que o trabalhador desempenha a atividade, nos termos da súmula da TRU supracitada, mostra-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre tal rubrica.

Portanto, o autor possui o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, observado o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda, nos termos do que determina o art. 168 do CTN e art. 3º, da Lei Complementar nº 118/2005, bem como conforme a interpretação determinada no RE nº 566.621 julgado em repercussão geral.

Por oportuno, cumpre asseverar que, sobre o indébito tributário a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, as parcelas devidas deverão ser remuneradas, desde quando descontadas, pelo índice da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, o qual representará, simultaneamente, atualização monetária e juros de mora, não podendo incidir cumulativamente com outro índice de correção monetária.

Precedente, *mutatis mutandis*, da 6ª Turma Recursal (Processo 5000135-71.2018.4.02.5118, relatora Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgamento em 08/05/2019, por unanimidade).

Ante o exposto, voto por CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos da fundamentação supra. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se as partes e transitado em julgado, certifique-se, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.